

SALAHUDIN GHAFAR@GAVIN EDWARD O'LUANAIGH

lawan

SERINA BINTI REDZUAWAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 31 Januari 2022 / 28 Jamadil Akhir 1443H

Kes Mal (Rayuan) No. 10000-026-0081-2020

[Rayuan Terhadap Perintah Hak Jagaan Anak]

Peguam Syarie Pemohon : Dato' Zainul Rijal bin Abu Bakar dari Chambers Of Zainul Rijal.

Peguam Syarie Responden : Farah Wahida binti Mohammad Amin dari Tetuan Amli & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas sebahagian keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes no. 10200-026-0124-2018 yang telah diberikan pada 26/8/2020. Penghakiman kes tersebut seperti mana berikut:-

1.1 Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff untuk mengubah Penghakiman Persetujuan pada 27/7/2017 melalui saman no. 10300-028-0333-2017

berdasarkan seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003;

- 1.2 Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak bernama Isabella Safiyya O'luanaigh (no mykid : 120123-14-1150) (anak kedua tersebut) diserahkan kepada Plaintiff;
- 1.3 Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak bernama Tristan Tareef O'luanaigh (no mykid : 100913-14-0971) (anak pertama tersebut) diserahkan kepada Defendan;
- 1.4 Hak lawatan bersama anak-anak tersebut diberikan kepada yang tidak mendapat hak jagaan pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan makluman awal kepada pihak yang menjaga;
- 1.5 Mahkamah memerintahkan hak bermalam anak kedua tersebut diberikan kepada Defendan pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan dengan mengambil anak kedua tersebut di kediaman Plaintiff dan/atau dimana-mana tempat yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dan diambil pada jam 7.00 malam hari Jumaat dan akan mengembalikan anak kedua tersebut pada jam 6.00 petang hari Ahad;
- 1.6 Mahkamah memerintahkan hak bermalam anak pertama tersebut diberikan kepada Plaintiff pada minggu kedua dan keempat setiap bulan dengan mengambil anak kedua tersebut di kediaman Plaintiff dan/atau dimana-mana tempat yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dan

diambil pada jam 7.00 malam hari Jumaat dan akan mengembalikan anak kedua tersebut pada jam 6.00 petang hari Ahad;

1.7 Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada cuti persekolahan penggal hendaklah dibahagi sama rata antara Plaintiff dan Defendan;

1.8 Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada hari-hari perayaan diberikan secara bergilir-gilir setiap tahun antara Plaintiff dan Defendan seperti berikut:-

8.1 Aidilfitri bagi tahun 2021/1442H – Plaintiff diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut sepenuhnya. Manakala Aidilfitri 2022/1443H – Defendan diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut sepenuhnya. Anak-anak tersebut boleh diambil selewat-lewatnya sehari sebelum perayaan Aidilfitri mulai jam 10.00 pagi dan dipulangkan selewat-lewatnya pada jam 6.00 petang sehari sebelum cuti sekolah berakhir.

8.2 Aidiladha bagi tahun 2021/1442H – Defendan diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut sepenuhnya. Manakala Aidiladha 2022/1443H – Plaintiff diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut sepenuhnya. Anak-anak tersebut boleh diambil selewat-lewatnya sehari sebelum perayaan Aidilfitri mulai jam 10.00 pagi dan dipulangkan selewat-lewatnya pada jam

6.00 petang sehari sebelum cuti sekolah berakhir dan begitulah pada tahun-tahun berikutnya dibuat secara bergilir-gilir mengikut tahun.

1.9 Mahkamah memerintahkan bahawa Plaintiff dan/atau Defendan dan/atau agennya dan/atau mana-mana wakil dari kedua-dua pihak adalah ditegah dan dilarang membawa anak-anak tersebut keluar dari Malaysia;

1.10 Mahkamah memerintahkan kesemua dokumen anak-anak tersebut termasuk sijil kelahiran, mykid dan passport anak-anak tersebut diserahkan kepada pihak yang menjaga bagi memudahkan segala urusan berkaitan anak-anak tersebut;

1.11 Mahkamah memerintahkan bahawa Penghakiman Persetujuan bertarikh 27/7/2017 bagi kes saman no. 10300-028-0333-2017 dibatalkan.

Fakta Kes

[2] Perayu dan Responden telah bernikah pada 1/1/2010 dan telah bercerai pada 1/8/2017. Hasil perkahwinan Perayu dan Responden, mereka telah dikurniakan dengan dua (2) orang anak iaitu *Tristan Tareef O'luanaigh* (no mykid: 100913-14-0971)(anak pertama tersebut) dan *Isabella Safiyya O'luanaigh* (no mykid: 120123-14-1150)(anak kedua tersebut).

[3] Pada 27/7/2017, suatu perintah penghakiman persetujuan berkaitan hak jagaan anak pertama dan anak kedua tersebut telah dibuat dalam kes saman no. 10300-028-0333-2017 oleh pihak-pihak dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari mana-mana pihak ketiga. Semasa perintah penghakiman persetujuan hak jagaan dikeluarkan anak pertama dan anak kedua tersebut masing-masing berumur 7 tahun dan 5 tahun.

[4] Responden kemudiannya telah memfailkan suatu tuntutan ubah perintah hak jagaan terhadap anak pertama dan anak kedua tersebut melalui kes no: 10200-026-0124-2018. Pada 26/8/2020, Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana di perenggan [1] diatas.

[5] Tidak berpuashati dengan sebahagian keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan notis rayuan pada 27/8/2020 dan memfailkan alasan rayuan pada 23/11/2020 dengan memplidkan lapan (8) alasan rayuan seperti mana yang tertera di muka surat 724-728 rekod rayuan. Perayu berhasrat untuk merayu terhadap sebahagian daripada perintah tersebut iaitu pereggan 1 dan 2 perintah yang seperti berikut:-

- i. *Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff untuk mengubah Penghakiman Persetujuan pada 27/7/2017 melalui saman no. 10300-028-0333-2017 berdasarkan seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga islam (Selangor) 2003; dan*

- ii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak bernama Isabella Safiyya O'luanaigh (no mykid: 120123-14-1150) (anak kedua tersebut) diserahkan kepada Plaintiff.*

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Setelah kami meneliti notis rayuan Perayu, rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami berpendapat terdapat satu isu utama sahaja yang perlu kami ulas dan putuskan iaitu **samada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dalam membuat keputusan bahawa hak jagaan anak yang bernama Isabella Safiyya O'luanaigh (no mykid: 120123-14-1150)(anak kedua tersebut) diserahkan kepada Responden selaku ibu kandung tanpa berdasarkan pilihan anak yang memilih untuk tinggal bersama Perayu (bapa).**

[7] Ulasan kami ini adalah berkait dengan alasan rayuan pertama, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh Perayu. Perayu berhujah bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf, gagal dan/atau tersasar dari segi fakta dan/atau undang-undang apabila tidak mengambil kira pilihan anak kedua tersebut walaupun telah jelas anak kedua tersebut telah memilih bapa kandung (Perayu) sebagai penjaga memandangkan sejak kecil anak kedua tersebut tidak pernah berpisah dengan Perayu. Hujah Perayu juga berkisar kebajikan anak kedua tersebut memandangkan anak kedua tersebut telah sekian lama tinggal dan menetap bersama Perayu.

[8] Perayu telah merujuk kepada alasan penghakiman Hakim Bicara di perenggan 19 muka surat 19 yang telah menyatakan:-

“oleh yang demikian, anak pertama dan kedua wajar dipanggil dan diberikan peluang membuat pilihan sama ada untuk memilih tinggal dengan ibu atau bapa kandung. Menurut Perayu Hakim Bicara telah gagal memanfaatkan hasil perjumpaan bersama anak kedua tersebut.”

[9] Perayu juga menyatakan bahawa usia anak kedua tersebut pada masa material ini telahpun meningkat umurnya dan semasa penghujahan bertulis ini difailkan, anak kedua tersebut telahpun mumayyiz dan wajar dipanggil bagi menentukan pemilihan hadhinah. Perayu berhujah dengan merujuk kepada kes Razua Nastira binti Ahmad Tajudin lawan Aized Ismed bin Mohd Zin.

[10] Responden dalam hujah balasnya menyatakan bahawa Hakim Bicara sama sekali tidak terkhilaf apabila di dalam prosidingnya meraikan seksyen 85 (2) dan 87 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 untuk anak pertama dan anak kedua tersebut membuat pilihan dan tidak semestinya mengikat Hakim Bicara membuat keputusan berdasarkan pilihan anak-anak tersebut.

[11] Menurut Responden lagi, apa yang menjadi keutamaan dan keberatan Hakim Bicara adalah melihat kepada kebajikan dan ajaran Islam anak-anak tersebut berbanding mengambil kira pilihan anak-anak tersebut untuk tinggal bersama bapa mereka iaitu Perayu. Hakim Bicara tidak mengambil kira pilihan anak kedua tersebut berdasarkan aqidah dan kebajikan anak-anak tersebut apabila memilih hendak tinggal dan/atau berada di bawah jagaan Perayu. Dalam hal ini

Responden berhujah dengan merujuk kepada kes *Tunku Mahmood Shah Mohammad lawan Noor faridah Sutherland Abdullah [2004] CLJ (Sy) m/s 602.*

[12] Responden juga merujuk kepada perenggan 28 Alasan Penghakiman (muka surat 718 rekod rayuan) bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf dengan pendapatnya apabila Responden selaku ibu wajar diberi peluang untuk mendidik anak-anak dengan ajaran agama Islam.

[13] Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya (rekod rayuan, muka surat 707-721) telah memanggil anak-anak tersebut dan telah diberi peluang membuat pilihan samada untuk memilih tinggal dengan ibu kandungnya atau bapa kandungnya. Sesi temubual telah diadakan oleh Hakim Bicara pada 29/6/2020. Kedua-dua telah hadir untuk temubual dan telah memilih untuk tinggal bersama Perayu iaitu bapa mereka.

[14] Hakim Bicara kemudiannya membuat dapatan bahawa bersetuju dengan pilihan anak pertama untuk tinggal bersama bapanya dengan alasan bahawa anak pertama tersebut seorang anak lelaki yang telah melebihi umur 7 tahun dan seorang anak yang telah mencapai umur mumayyiz. Maka Hakim Bicara boleh menerima pandangan anak tersebut.

[15] Manakala anak kedua, iaitu seorang anak perempuan yang belum mencapai umur 9 tahun dan belum mumayyiz, maka menurut Hakim Bicara wajar anak tersebut bersama ibunya (Responden). Hakim Bicara dalam alasan penghakimanya menyatakan seperti berikut:-

“Mahkamah tidak mengambil kira pilihan anak kedua tersebut. Ini berikutan pihak plaintif tidak hilang kelayakan menjadi hadinah bagi anak tersebut. Meskipun Mahkamah tidak menafikan hak Defendan selaku bapa juga berkelayakan menjadi hadinah. Namun ibu adalah penjaga yang terbaik bagi anak perempuan tersebut bagi memastikan kebajikan dan pendidikan anak tersebut terus terpelihara.”

[16] Dalam kes di hadapan kami ini, *subjek matter* ialah “*hak al mahdhun*” kanak-kanak itu sendiri yang telah melalui fasa-fasa perubahan selari dengan peningkatan usia dan keperluan. Kami dapati semasa perintah persetujuan hadhanah dikeluarkan pada 27/7/2017, usia anak-anak tersebut adalah anak pertama berusia 7 tahun dan anak kedua berumur 5 tahun. Kemudian semasa kes perubahan perintah hadhanah dikeluarkan pada 26/8/2020, anak pertama telah mencapai umur lebih kurang 9 tahun 10 bulan dan anak kedua berumur 8 tahun 6 bulan. Seterusnya semasa kes di hadapan kami hari ini kedua-dua anak tersebut telah masing-masing berumur lebih kurang 12 tahun dan sepuluh 10 tahun.

[17] Kami juga mendapati Hakim Bicara telah memanggil anak-anak tersebut pada 29/6/202. Hasil temubual kedua-dua anak telah memilih untuk tinggal bersama Perayu. Namun dapatan Hakim Bicara di muka surat 716 rekod rayuan menyatakan bahawa :-

Mahkamah bersetuju dengan bersetuju dengan pilihan anak pertama untuk tinggal bersama Defendan (bapa). Anak pertama adalah anak lelaki, telah melebihi umur 7 tahun. Anak tersebut telah mencapai umur mumaayyiz.

Mahkamah berpendapat usia anak perempuan belum mencapai umur 9 tahun dan belum mencapai umur mumayyiz, maka wajar anak kedua tersebut bersama ibunya (Plaintif). Mahkamah tidak mengambil kira pilihan anak kedua tersebut.

[18] Berdasarkan ulasan di atas, pada hemat kami Hakim Bicara telah berpuas hati dengan sesi temubual bersama anak pertama dan anak kedua tersebut dan membuat keputusan dengan mengambil kira tahap mumayyiz anak-anak tersebut. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara apabila melibatkan anak yang “belum mumayyiz” (anak kedua sebagaimana dalam rayuan Perayu ini) semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi, maka ia tertakluk kepada ‘*status quo*’ undang-undang berdasarkan seksyen 82(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) yang menyatakan bahawa –

Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.

[19] Peruntukan seksyen 82(1) Enakmen tersebut secara jelas menyatakan bahawa ibu adalah pihak yang paling berhak terhadap hak penjagaan anak kecil (belum mumayyiz) dan hak ini diberikan kepada ibu tersebut apabila ia memenuhi syarat kelayakan sepertimana yang dinyatakan pada peruntukan seksyen 83 Enakmen. Seksyen 83 Enakmen yang menyatakan bahawa –

Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, adalah berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika—

(a) dia adalah seorang Islam;

- (b) dia adalah sempurna akal;
- (c) dia berumur yang melayakkan dia memberikan kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu;
- (d) dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan
- (e) dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.

[20] *Status quo* ini juga telah diulas oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor sebagai anggapan undang-undang melalui seksyen 82 Enakmen di dalam kes Abdul Malek Bin Abdul Kadir lwn Zulzilawati Binti Jusoh, Kes Rayuan (Selangor) No. 10000-028-0084-2016. Melalui '*status quo*' atau anggapan undang-undang tersebut, soal penentuan penjaga kepada kanak-kanak yang kecil dan belum mumayyiz ini menjadi mudah dan cepat diputuskan jika si ibu tersebut memenuhi syarat-syarat kelayakan menjadi hadinah.

[21] Pada hemat kami juga, Hakim Bicara dalam memutuskan ubah perintah hadhanah terhadap anak kedua tersebut, adalah terikat dengan prinsip anggapan undang-undang bahawa ibu adalah orang paling berhak mendapat hak jagaan melainkan sekiranya Perayu berjaya membuktikan ketidaklayakan Responden menjadi penjaga di bawah seksyen 84 Enakmen, pada masa material kes ini difailkan. Ini juga bertepatan dengan *kaedah fiqhiyyah* iaitu –

الأصل بقاء ماكان على ماكان

“Sesuatu itu adalah kekal seperti mana asalnya”

[22] Kami tegaskan bahawa isu masalah anak hendaklah diutamakan berbanding kehendak ibu dan bapa kanak-kanak tersebut. Perkara ini sepertimana dinyatakan dan dijelaskan di dalam kitab Fiqh As-Sunnah, Syed Sabiq Juz 8 halaman 219 yang menyatakan –

إن لكل من الحضانة والمحضون حقا في الحضانة, إلا أن حق المحضون أقوى من
الحضانة

Bermaksud: “Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya”

[23] Perkara yang sama juga telah diulas oleh Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob[2004] JH 17(1) iaitu –

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

[24] Kami berpuas hati dan merumuskan bahawa Hakim Bicara telah memutuskan hak jagaan anak kedua diberikan kepada Responden bersandarkan isu kebajikan anak tersebut pada masa itu adalah seorang anak perempuan yang belum mumayyiz dan anggapan undang-undang yang memberi kedudukan positif kepada Responden sebagai hadhinah anak kedua tersebut adalah betul.

[25] Seterusnya adalah isu yang berkaitan dengan alasan rayuan kedua Perayu. Dalam isu ini Perayu menyatakan bahawa Responden telah mengguna pakai seksyen 77 Enakmen bagi mengubah perintah persetujuan hadhanah. Walaupun begitu menurut Perayu Hakim Bicara telah menyatakan bahawa seksyen 76 Enakmen Keluarga Islam (Selangor) 2003 lebih bertepatan dengan kes ini.

[26] Perayu menghujahkan bahawa tuntutan mengubah perintah persetujuan bagi hak jagaan hadhanah yang difailkan oleh Responden adalah tidak wajar, tidak relevan, tiada keperluan serta tidak munasabah sama sekali untuk dibenarkan.

[27] Responden menyatakan didalam tuntutannya, telah menggunakan seksyen 77 Enakmen yang mana pada pandangan Hakim Bicara tidak bersesuaian dengan tuntutan Responden, dan Hakim Bicara telah menggunakan seksyen 76 Enakmen dengan alasan telah berlaku perubahan matan pada anak-anak tersebut.

[28] Responden berhujah dengan menyatakan Hakim Bicara sama sekali tidak terkhilaf apabila berpendapat penggunaan seksyen 76 Enakmen lebih bersesuaian memandangkan berlakunya perubahan matan terhadap umur mumayyiz ana-anak tersebut.

[29] Berkenaan isu ini, kami merujuk kepada Alasan Penghakiman Hakim Bicara dimuka surat 717 Rekod Rayuan yang mana hakim Bicara menyatakan:-

[24] Mahkamah berpendapat penggunaan seksyen 77 EUUKIS 2003 tidak bersesuaian bagi tuntutan untuk mengubah penghakiman persetujuan

hadhanah disebabkan seksyen 77 lebih mengkhususkan terhadap perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak.....

[25] Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat seksyen 76 lebih sesuai dalam tuntutan mengubah penghakiman persetujuan hadhanah disebabkan ianya seksyen yang khusus untuk mengubah perintah Mahkamah.....

[30] Kami merujuk kepada seksyen 76 Enakmen yang memperuntukkan berkenaan kuasa Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seorang anak apabila perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan. Manakala seksyen 77 Enakmen memperuntukkan berkaitan kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak iaitu mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian berkaitan dengan penjagaan atau nafkah.

[31] Dalam hal ini, kami mendapati Hakim Bicara telah mengulas dengan terperinci berhubung dengan dapatan beliau dalam menentukan hak jagaan terhadap anak-anak tersebut khususnya berdasarkan perubahan matan yang telah berlaku kepada umur anak-anak tersebut. Maka kami tidak dapat mempertimbangkan hujah Perayu kerana pada hemat kami, Hakim Bicara boleh menggunakan kuasa dan budibicara yang diberikan kepadanya untuk memutuskan berkenaan ubah perintah hak jagaan dan lawatan anak pada bila-bila masa dengan merujuk mana-mana peruntukan yang bersesuaian, berdasarkan keterangan dan fakta yang dikemukakan di hadapan beliau. Pada hemat kami, Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila berpendapat perintah wajar diberikan

tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003.

[32] Selanjutnya kami tidak bercadang untuk mengulas isu berkaitan karektor dan peribadi Responden yang didakwa tidak berakhlak dan cukup kami timbulkan sedikit persoalan bahawa “adakah jika seseorang itu pernah berkelakuan tidak baik dari segi akhlak Islamiah akan selamanya tidak layak/berhak dari segi undang-undang dan hukum Syarak menjalankan hak terhadap hadhanah akibat dari perbuatannya itu walau pun dia telah menjadi seorang yang baik?”.

[33] Kami sering mendapati, telah menjadi kebiasaan di Mahkamah dalam kes tuntutan hak jagaan anak, di mana pihak-pihak sering mahu membuktikan ketidakupayaan atau ketidak layakan pihak satu lagi untuk mendapat hak jagaan. Oleh yang demikian, maka pihak-pihak akan sedaya upaya cuba untuk memburukkan atau membuktikan kepada mahkamah tentang kekurangan serta keburukan pihak yang satu lagi.

[34] Kami berpendapat, amalan sedemikian bukanlah suatu amalan yang baik. Ianya tidak patut dibiarkan berterusan kerana ianya seolah-olah akan menjadikan perbicaraan di Mahkamah adalah bagi menentukan siapakah yang lebih buruk perilakunya dan bukannya membuktikan kepada Mahkamah siapakah yang paling memberikan atau lebih memelihara kebajikan kanak-kanak tersebut jika hak jagaan diberikan kepadanya sepertimana kehendak subseksyen 87(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor).

[35] Dalam kitab al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Sahsiyyah Baina al-Madhahib al-Arba'ah al-Sunniyyah wa al-Madhab al-Ja'fari wa al-Qanun, karangan Badran Abu Ainain Badran ada menyebutkan, yang bermaksud –

“Sebenarnya, tujuan hadhanah adalah ditujukan kepada kanak-kanak itu adalah lebih utama kerana kepentingannya hendaklah didahulukan dari kepentingan kedua ibu bapanya. Sesungguhnya, wajiblah mengutamakan kebajikan mereka adalah lebih utama dalam bab hadhanah ini.”

[36] Dalam memutuskan siapakah yang layak untuk mendapat hak jagaan terhadap seorang kanak-kanak, Mahkamah dipandu oleh statut yang menyatakan bahawa *“pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu”*. Oleh itu, kebajikan kanak-kanak adalah menjadi pertimbangan yang utama dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mendapat hak jagaan di sisi undang-undang dan hukum Syarak.

[37] Berkenaan alasan rayuan ketiga dan kelapan Perayu, kami dapati ia adalah berkaitan dengan hak lawatan ke atas anak pertama dan anak kedua tersebut. Merujuk kepada hukum Syarak, apabila melibatkan anak-anak yang telah mumayyiz, hadhanah sahaja adalah terpulang kepada kehendak anak-anak untuk membuat pilihan, tetapi lawatan ke atas anak adalah hak ibu/bapa yang bukan pilihan anak. Hadith dan pandangan ulama' yang dirujuk berkaitan hak memilih oleh anak-anak adalah seperti berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بابني , وقد سقاني من بئر أبي عتبة . وقد نفعتني , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (استهما عليه) . فقال زوجها : من يحافني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (هذا أبوك , وهذا أمك , فخذ بيد أيهما شئت) . فأخذ بيد أمه , فانطلقت به . (رواه احمد والأربعة وصححه الترمذی ورواه أبو داود وابن ماجه).

Maksudnya: 'Daripada Abu Hurairah r.a, katanya: telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah s.a.w. seraya berkata: 'Wahai Rasulullah s.a.w., sesungguhnya suamiku hendak membawa anakku bersamanya, sedangkan anakku telah menolongku mengambil air daripada telaga Abi Inabah, dan anakku banyak memberi faedah kepadaku daripada pertolongannya itu'. Maka Sabda Rasulullah s.a.w: 'Hendaklah kamu berdua membuang undi tentang anak kamu.' Maka suaminya itu menjawab: 'Siapakah yang boleh menghalang hakku tentang anakku ini.' Lalu Baginda Rasulullah s.a.w berkata kepada anak itu: 'Ini bapa kamu dan ini pula ibu kamu, maka pilihlah siapa di antara kedua-duanya yang engkau suka tinggal bersama.' Maka anak itu pun memilih ibunya dengan memegang tangan ibunya itu, lalu perempuan itupun membawa anaknya itu pulang bersamanya.

(Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah)

[38] Ismail San'ani dalam kitab Subul al-Salam Jilid 3 hal. 228 memberi pandangan berkaitan hadith tersebut dengan katanya:

فقد دل الحديث على أنه بعد استغناء الصغير بنفسه , يخير بين أبويه .

Maksudnya: Hadith di atas menunjukkan bahawa kanak-kanak yang sudah boleh menguruskan dirinya dengan sendiri diberi pilihan untuk tinggal dengan salah seorang daripada kedua ibubapanya.

[39] Dalam hal ini, kami dapati ibu/bapa mempunyai hak untuk memastikan ia dapat menziarahi anaknya, supaya tanggungjawab ibu/bapa dapat tercapai dari segi mendidik dan mengajar anak- anak itu. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz. 7, hal 7321 menyebutkan:

والحنابلة كالشافعية قالوا : ان اختار المميز أباه كان عنده ليلا و نهارا , ولا يمنع من زيارة أمه , ولا تمنع هي من تمريره . وان اختارها كان عندها ليلا , وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه .

Maksudnya: 'Mengikut pendapat mazhab Hanbali dan juga mazhab al-Syafie: sekiranya anak yang mumayyiz memilih bapanya, maka ia bersama bapanya siang dan malam, dan bapa tidak boleh melarangnya bagi menziarahi ibunya, dan juga bapanya tidak boleh melarang ibunya merawat anak itu bila anak itu sakit. Sekiranya anak itu memilih ibunya, maka anak itu bersama ibunya pada waktu malam, dan bersama bapanya pada waktu siang supaya bapa dapat mendidiknya dan mengajarkannya.'

[40] Suka kami tegaskan dalam hal ini, Perayu atau Responden adalah berhak untuk mendapat hak bersama dan bermalam serta hak berhari raya dengan kedua-dua anak tersebut, bahkan perintah yang diputuskan oleh Hakim Bicara adalah perintah yang relevan dan wajar demi menjaga hubungan silaturahim dan memberi ruang kepada pihak-pihak untuk menjalankan tanggungjawab mendidik anak-anak tersebut serta dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Kami tegaskan bahawa hak bersama dan bermalam serta hak berhari raya yang diberikan kepada ibu atau bapa yang tidak diberikan hak jagaan tersebut adalah merupakan suatu tuntutan yang wajar dan munasabah yang tidak wajar dipertikaikan. Ini kerana berdasarkan perundangan keluarga Islam di Mahkamah-mahkamah Syariah, tuntutan berhubung hak bersama dan bermalam serta hak berhari raya adalah dibenarkan berdasarkan keperluan yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah.

[41] Berbalik kepada isu utama kes di hadapan kami ini, dapatan kami telah berlaku perubahan matan yang memberi kesan undang-undang terhadap hak jagaan anak kedua tersebut terutamanya terhadap kondisi umur anak itu yang telah mencapai umur mumayyiz semasa rayuan ini didengar. Ketika kes ubah perintah hadhanah diputuskan oleh Hakim Bicara pada 26/8/2020, anak kedua itu berumur 8 tahun 6 bulan dan di hadapan kami pada hari ini telah berumur lebih kurang 10 tahun dan 8 hari.

[42] Pada hemat kami, adalah perlu bagi Mahkamah melakukan ujian demi kekal menjaga kebajikan dan kemaslahatan anak kedua tersebut. Ujian yang dimaksudkan adalah memerlukan Hakim menemubual anak kedua tersebut sekali lagi setelah berlaku perubahan dan mengetahui pilihan dan alasan anak kedua tersebut untuk memilih *hadhinah* atau *hadinnya*.

[43] Kami bersetuju dengan hujah Perayu untuk memanggil dan menemubual anak kedua tersebut tetapi pada hemat kami, korum yang sesuai untuk menentukan hal tersebut adalah korum di dalam kes Tuntutan Ubah Perintah / Penghakiman yang boleh dimohon oleh pihak-pihak di bawah seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) di Mahkamah Bicara.

[44] Ini kerana, kami berpendapat penentuan hak jagaan dan terma lawatan yang bersesuaian dan adil termasuk cuti persekolahan dan berhari raya tidak dapat ditentukan oleh kami pada hari ini, kerana kami tidak berpeluang untuk mendengar dan meneliti keterangan langsung pihak-pihak, lebih-lebih lagi dalam

situasi telah berlakunya perubahan matan terutamanya terhadap kondisi umur anak kedua tersebut serta perubahan terhadap tempoh masa yang dilalui olehnya.

[45] Kami melihat peruntukkan undang-undang dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam adalah mendengar kepada keterangan pihak-pihak untuk mendapatkan hak jagaan semasa, dan kes dibicarakan seterusnya dapatan semasa hal keadaan anak-anak. Walau bagaimanapun apabila berlaku rayuan, hanya rekod keterangan dinilai sedangkan dalam masa yang sama perubahan telah berlaku terhadap anak kedua tersebut.

[46] Pada kesempatan ini sebagai peringatan, kami kemukakan pandangan Hakim Bicara di dalam kes Charlotte Mary Erica Leng lwn. Anis Sani Bin Ariffin, JH 47(2) bahawa kedua-dua pihak hendaklah mematuhi apa-apa perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses pelaksanaan perintah Mahkamah berjalan lancar. Kedua-dua pihak juga hendaklah memberikan kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak tersebut.

[47] Allah telah berfirman di dalam Surah al Anfal ayat 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Maksudnya: “Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.”

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Rekod Rayuan, Notis Rayuan Perayu, Alasan Rayuan Perayu dan Hujah Bertulis pihak-pihak, MAKA Kami sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:-

[1] Rayuan Perayu DITOLAK.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

.....
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATH**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

.....
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.